

Tipología: ensayo de la desif y sistematización de los múltiples conceptos constitucionales en un solo tipo de tipos agrupando a sus notas y caracteres comunes.
48 TEORÍA CONSTITUCIONAL
(Se describe como se colige)

y con la acción de la asociación, para el caso que trate de imponer una nueva Constitución”.

Hans Kelsen, profesor de la Universidad de Viena y asesor de la Corte en 1919, coincide con Max Weber, primero, en que “la nota esencial del Estado es el monopolio de la fuerza cuya utilización entonces deviene legítima”; segundo, “en que la justicia es un sentimiento irracional”; tercero, “en que el derecho positivo está conformado por una ideología, esto es a tenor de los intereses de quienes detentan el poder”; y cuarto, “en que el estudio del derecho constituye una ciencia en tanto que es ciencia del derecho positivo formal”. Precisamente, para fundamentar esta ciencia “pura” del derecho, Hans Kelsen recurre a la filosofía neokantiana de la escuela de Hamburgo, que artificialmente hace una separación absoluta entre la raíz cognoscitiva de los juicios de valor, que surgirán de la esfera emocional y afectiva de la conciencia, y la de los juicios objetivos científicos, emergentes de su esfera racional e intelectual. Para Kelsen, entonces, Constitución es el conjunto de normas fundamentales vigentes.

Arturo Sampay, profesor en las universidades de La Plata y Buenos Aires, afirma que el término “Constitución” proviene de la voz latina *constituere* (juntos estatuir). Etimológicamente significa, “con una pluralidad de individuos, instituir algo”. Agrega Sampay que es “el modo de ser que adopta una comunidad política en el acto de crearse, de recrearse o de reformarse”. El acto fundador o refundador de la comunidad política puede ser de lento o de súbito desarrollo, conforme sea el ritmo que lleve el curso de la historia.

TIPOLOGÍA DE LOS CONCEPTOS DE CONSTITUCIÓN.

La variedad de los conceptos de Constitución ha obligado a los autores a formular sus tipologías al respecto. Friedrich, citado por Linares Quintana, afirma que la tipología “es una parte importante de la teoría política, y lo mismo puede decirse de la metodología. El reconocimiento de lo que es típico en una clase de objetos o eventos está por debajo de toda formulación conceptual: por lo que la tipología forma parte de toda investigación en la relación de la experiencia con su conceptualización. Un resultado en tipología, dice Friedrich, es un resultado sobre la estructura de la realidad que está en el campo de ésta y, como tal, se relaciona estrechamente con el ordenar y la ordenación” (Segundo V. Linares Quintana, *Derecho constitucional e instituciones políticas*, Abeledo Perrot, Bs. As., 1970, t. I, p. 413).

Las tipologías convencionales más importantes son las de

Constit. se relaciona con el orden polít. de 1 país y se
auto de fondo 1 forma dist. de o. polít.

- a) Posada; b) García Pelayo; c) Hermann Heller; d) Schmitt; e) Kelsen.

a) Tipología de Posada. Posada afirma, en su obra *Tratado de derecho político* (1924), luego de repasar los conceptos de Constitución, que "por Constitución política estimase, en general, la expresión jurídica del régimen del Estado con respecto a la organización de los poderes o instituciones fundamentales en las que encarna prácticamente el ejercicio de la soberanía y a la limitación de la acción de esos poderes en sus relaciones con la personalidad humana". En definitiva, la Constitución es un conjunto de garantías y la organización política de un Estado.

Las Constituciones pueden ser: I) un pacto; II) una carta; III) un estatuto fundamental o IV) puede ser impuesta por el pueblo al monarca.

I) En ciertas oportunidades son un pacto entre el rey y el pueblo, en el que se acuerdan ciertos derechos y obligaciones. Así lo declara expresamente la Constitución dada por Napoleón a España en 1808.

II) Pueden ser también una carta otorgada graciosamente por un monarca absolutista en la que se establecen determinadas libertades para sus súbditos.

III) En otras oportunidades son estatutos fundamentales, elaborados por asambleas constituyentes, tal es el caso de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y la de la República Argentina de 1853.

IV) Asimismo, pueden ser imposiciones del pueblo al rey, como el restablecimiento de la Constitución de 1812 que debió realizar en España el rey Fernando VII, en 1823.

Los textos de las Constituciones escritas de los Estados modernos tienen como objeto establecer, consagrar y hacer efectivo un orden de garantías de la vida individual y social en sus relaciones con los poderes públicos y delimitar y organizar las funciones de los órganos del gobierno del Estado. Toda Constitución escrita tiene una parte dogmática y otra orgánica. El derecho constitucional tiene como fin, para Posada, crear el derecho para el Estado y el monarca o el gobierno representativo deben ajustarse a las exigencias de ese derecho.

- b) Tipología de García Pelayo. García Pelayo sostiene que existe una pluralidad de formulaciones del concepto de Constitución, siendo éstos los siguientes: I) El concepto racional normativo. II) El concepto histórico tradicional. III) El concepto sociológico.

I) El concepto racional normativo determina que una Cons-

repositan sobre 9/10 de las p. con la finit. polít. soc. del S. XIX.

titución es un complejo normativo establecido de una vez y en el que, de una manera total, se fijan las funciones fundamentales del Estado. La Constitución es, pues, un sistema de normas.

(Puede ser la renovación del pacto social o la necesidad de establecer normas por escrito al romper con la tradición.) Según García Pelayo, la finalidad principal de la Constitución consiste en asegurar los derechos individuales y es evidente que una garantía esencial para ello lo proporciona el hecho de que los poderes constituidos no pueden modificar por sí mismos el esquema constitucional. Al concepto racional de Constitución le es inherente la distinción entre poder constituyente y poder constituido (v.), ya que solamente al primero le corresponde decidir sobre la Constitución en su totalidad.

II) El concepto histórico tradicional surge en su formulación como una actitud polémica frente al concepto racional normativo, o, dicho de otra manera, como una ideología del conservadorismo frente al liberalismo. El revolucionario mira al futuro y cree en la posibilidad de conformarlo; el conservador ve el pasado y lo considera como algo inmutable. Esta antinomia se hace evidente a partir del siglo XVIII y fundamentalmente en el siglo pasado; la oposición entre razón e historia; entre racionalismo o naturalismo e historicismo es evidente y profunda. García Pelayo, en su obra Derecho constitucional comparado, hace la distinción entre dos grupos antagónicos: 1) quienes consideran a la Constitución como algo puramente histórico y a la historia como una disciplina rebelde a la razón y planificación humana, y 2) quienes creen que la razón es capaz de moldear a la historia en cierta medida y de planificar el futuro. A partir de tales premisas, García Pelayo afirma que tales Constituciones no necesitan ser escritas en su totalidad, sino que la costumbre debe tener una abundante participación, como corresponde a una teoría del derecho con base historicista. Este enfrentamiento entre derecho positivo y derecho consuetudinario lo lleva a manifestar la diferencia entre leyes ordinarias y leyes constitucionales.

III) El concepto sociológico de la Constitución es, según García Pelayo, la proyección de la sociología al ámbito constitucional y se basa en las siguientes consideraciones: 1) la Constitución no es una forma de deber ser sino una forma de ser, y 2) la Constitución es el resultado de estructuras y situaciones de la actualidad.

VIGENCIA

De los tres conceptos de Constitución enumerados, sólo el racional normativo ha tenido trascendental importancia en la evolución del derecho constitucional. Los otros dos tuvieron impor-

es legit. y reflejo real. constit.

Constit. y el de ley's de los instit' tradicionales

tancia en la polémica política, pero no en la actividad jurídica.

Por ello, de conformidad con las ideas de García Pelayo la doctrina predominante debe ser la expuesta en el concepto racional normativo de Constitución.

c) *Tipología de Hermann Heller*. Según Hermann Heller, autor de *Teoría del Estado*, la Constitución del Estado coincide con su organización en cuanto ésta significa la Constitución producida mediante la actividad humana consciente.

Mediante esta forma de actividad humana, el Estado se convierte en una unidad ordenada de acción y es entonces cuando colma, en general, la existencia.

La Constitución del Estado no es, por eso, proceso, sino producto. Cabe distinguir entre una Constitución normada y otra no normada, la Constitución normada por el derecho es la Constitución organizada. La normalidad, en el derecho constitucional, es siempre reforzada por la normatividad. Mediante la obligatoriedad de esta última se intenta lograr un desempeño acorde con las metas del Estado. Lo normal en las conductas es lo que se convierte en norma y toda norma social aspira a tener validez general.

El contenido y la validez de las normas no está dado por su redacción o por los propósitos del legislador, sino por quien la recibe, que debe respetarla. Por eso una Constitución es real cuando son reales sus relaciones de poder.

d) *Tipología de Schmitt*. Schmitt, en su obra *Teoría de la Constitución* (1931), dice que la Constitución es el resultado de una serie de decisiones fundamentales. El derecho encuentra su fundamento en la voluntad y no en la razón, es decisión y no normatividad: "una Constitución es válida cuando emana de un poder (fuerza o autoridad) constituyente y se establece por su voluntad. La voluntad es una magnitud del ser como origen del deber ser. La voluntad se da de un modo existencial y su fuerza o autoridad reside en su ser".

Sigue afirmando Schmitt que el *Reich* (v.) alemán no se constituyó con los 181 artículos de la Constitución de Weimar (v.) "sino sobre la existencia política del pueblo alemán".

Distingue, en su tipología, 3 significados al término Constitución:

1. *Constitución en el sentido absoluto*, o sea la manera concreta de ser, resultante de cualquier poder existente, la concreta situación de conjunto de la unidad política y ordenación social de un cierto Estado.

2. *Constitución como manera especial de ordenación política*

y social, significa la supremacía de la Constitución y la subordinación de la realidad social a dichas normas.

3. *Constitución real dinámica*, derivada de la unidad política del fenómeno de la continuamente renovada formación y erección de esta unidad desde una fuerza y energía subyacente. Para Schmitt la Constitución es un sistema de normas supremas y últimas, es la ley de leyes y aquí se asemeja a Kelsen. Es válida cuando emana de un poder constituyente y se establece por su voluntad, que es la voluntad política del pueblo. Las leyes constitucionales, en cambio, valen tomando por base a la Constitución, por lo menos así se presume.

e) *Tipología de Kelsen*. Hans Kelsen (v.), autor de *Teoría general del Estado*, parte del supuesto de la identidad entre Estado y derecho y llega a la conclusión de que todo Estado es un ordenamiento jurídico, o sea un sistema dinámico de normas. La exigencia de validez de las mismas está determinada por su construcción lógica de que existen normas inferiores respecto de otras que son superiores —*pirámide jurídica* (v.)— y que la validez de las primeras está fundada en la existencia de las segundas o norma fundamental. Según Kelsen, una norma jurídica es válida cuando se la creó de una manera particular, según las reglas establecidas en la norma o ley fundamental. La existencia y validez de una norma, pues, está determinada por la existencia de otra, que es la Constitución.

Entonces, para Kelsen, una Constitución formal es un conjunto de normas jurídicas que solamente pueden ser modificadas mediante un procedimiento especial establecido en la propia Constitución.

Constitución material es el conjunto de preceptos que aseguran la creación de normas jurídicas generales, especialmente las leyes. Es más difícil reformar la Constitución formal, que sancionar las leyes generales. La Constitución formal, para Kelsen, puede ser escrita o no escrita, es decir, tener las características del derecho legislado o del consuetudinario.

Para determinar la validez de una Constitución debe remontarse hasta otra más antigua y llegar a la primera históricamente, que fue establecida por una asamblea, un monarca absoluto o un usurpador del poder.

TEORÍAS NUEVAS.

Como nuevas tipologías tenemos las de: a) Burdeau, b) Duverger, c) Loewenstein, y d) Xifra Heras.

a) *Tipología de Burdeau*. Georges Burdeau, autor de *Traité*